월간궤도

중소기업을 위한 월간 법률 실무 해제

제7호 · Issue 07
2026년 10월
발행 / 신한솔 변호사

이번 호 목차

섹션 01 — 신탁사의 책임을 묻는 방법과 한계

공사대금 직불합의, 책임한정특약, 시행사를 통한 계약과 채권회수

섹션 02 — 압수된 휴대폰을 돌려받는 법

증거와 범행 도구의 구별부터 환부와 가환부 그리고 수감 중 수령까지

섹션 03 — 이 달의 판례

부당이득 반환액을 공평의 원칙으로 줄일 수 있는가

편집자의 말 — 월간궤도가 다루는 것

월간궤도는 대구·경북 중소기업 오너와 실무자를 독자로 상정하는 월간 법률 해제지다. 본지 섹션 1은 매호 하나의 법률 분야를 택해, 사건이 어떤 절차를 따라 진행되는지, 어떤 법령·시행령·유권해석·판례가 그 절차를 지배하는지, 그리고 그 속에서 기업과 경영자가 법적으로 취할 수 있는 대응과 예방의 선택지는 무엇인지를 해부하는 것을 목적으로 한다.

본지는 필자가 직접 수행한 사건의 기록이 아니다. 현행 법령·시행규칙·유권해석·조세심판례·판례를 체계적으로 읽어내어, 그 속에 이미 정리되어 있는 실무 구조를 독자가 참조할 수 있는 형태로 풀어낸 해제다. 개별 사건의 진행은 변화무쌍하며 각 기관 절차의 실제 진행 속도에도 사안에 따라 수개월에서 수년에 이르는 편차가 있지만, 그것을 규율하는 법의 구조는 상대적으로 안정되어 있다. 본지는 그 구조를 전한다.

따라서 월간궤도는 읽어서 배우는 글이 아니라, 필요할 때 다시 찾아볼 수 있도록 쓴 글이다. 목차·조문·판례 사건번호가 빽빽한 이유는 이 때문이다. 경영의 현장에서 법이 작동하는 방식을 정확히 전달하기 위해, 본지는 읽기 편한 글보다 정확한 글을 지향한다.

신탁사의 책임을 묻는 방법과 한계

공사대금 직불합의, 책임한정특약, 시행사를 통한 계약과 채권회수

0. 도입

공사를 마쳤는데 시공사는 돈이 없고, 분양대금과 미분양 부동산은 신탁사가 관리하고 있다. 하도급업체는 신탁사가 서명한 직불합의서를 꺼내지만, 신탁사는 자금집행순서가 아직 돌아오지 않았다고 답한다. 수분양자는 계약을 해제하고 납입금을 돌려달라고 하지만, 이번에는 신탁재산의 범위 안에서만 책임진다는 특약이 나온다. 시행사와 거래할 때 기대했던 신탁사의 존재가, 돈을 받을 때에는 또 하나의 장애물이 되는 것이다.

그렇다고 신탁사는 어떤 경우에도 자기 돈으로 책임지지 않는다는 설명은 정확하지 않다. 신탁사가 계약상 채무를 부담하는지, 지급조건이 충족되었는지, 책임을 신탁재산으로 제한하는 약정이 유효하게 계약 내용이 되었는지는 서로 다른 문제이다. 신탁사 자신의 위법한 처분이나 대리권을 믿게 한 행위가 문제 되는 사건에서는 청구의 출발점도 달라진다.

이 글은 신탁사를 상대로 청구가 막힌 사건과 책임이 인정된 사건을 함께 살펴본다. 공사대금과 분양계약 분쟁을 중심으로, 신탁사의 답변 중 어느 부분을 다투어야 하는지, 그 다툼에 필요한 자료는 무엇인지, 판결을 받은 뒤 집행할 재산은 어디에 있는지를 구분한다.

1부 — 부동산을 가진 회사와 돈을 갚을 회사

1. 신탁사 명의라는 사실만으로 시행사의 빚을 떠안지는 않는다

부동산이 신탁되면 소유권은 수탁자인 신탁사에 이전된다. 시행사가 사업을 기획하고 분양사무실을 운영하며 현장을 사실상 지휘하더라도, 신탁부동산의 처분권한은 신탁사에 있다. 반대로 신탁사가 부동산을 소유한다는 이유만으로 시행사의 공사대금이나 차입금 채무를 모두 부담하는 것도 아니다.[1,5]

하나의 신탁사업에서는 토지와 건물뿐 아니라 분양대금, 처분대금과 관련 채권도 그 사업의 신탁재산을 이룬다. 이를 하나의 재산 묶음으로 생각하면 구조가 조금 선명해진다. 신탁사가 여러 사업의 부동산을 자기 명의로 보유하더라도, 각 사업의 신탁재산과 신탁사 자신의 고유재산은 구별된다. 신탁사 명의의 부동산이 아무리 많아도, 내 사업의 부족한 자금을 메울 재원은 그 사업의 신탁재산뿐이다.[1,3]

따라서 채권자는 등기부와 계약서를 나란히 놓아야 한다. 공사계약의 도급인이 누구인지, 신탁사가 그 계약을 인수하였는지, 별도의 지급약정을 하였는지, 단순히 자금관리자로 기재되었는지를 확인해야 한다. 신탁사의 직인은 서명한 자격과 조항을 함께 읽어야 의미가 생긴다. 자금집행에 협조한다는 약정과 지급채무를 부담한다는 약정은 같지 않다.

하도급업체라면 원도급계약까지 보아야 한다. 자기 계약의 상대방은 시공사인데 신탁사를 상대로 청구하려면, 하도급법상 직접지급청구권이나 직불합의 등 연결고리가 필요하다.[13] 그 연결고리를 확보하였더라도 신탁사가 시공사에게 부담하는 채무의 범위가 문제 될 수 있다. ‘현장에 들어간 공사비’라는 설명만으로 채무자가 바뀌지는 않는다.

2. 신탁사의 거절 사유를 구분해야 반박할 수 있다

신탁사가 ‘우리는 지급할 의무가 없다’고 한다면 계약당사자, 계약인수, 직접지급약정의 문제이다. ‘의무는 있지만 아직 지급순서가 아니다’라고 한다면 지급조건과 그 성취의 문제이다. ‘신탁재산 안에서만

책임진다’고 한다면 책임한정특약과 집행재산의 문제이다. 이 답변들을 모두 신탁사의 면책 주장으로 묶으면, 공사 완료와 미수금의 존재만 반복해서 증명하게 된다.

특히 신탁재산과 고유재산을 구별하는 것과, 모든 채무에 대한 책임을 신탁재산으로 제한하는 것은 다르다. 신탁법 제38조는 신탁행위로 인하여 수익자에게 부담하는 채무에 관한 규정이다. 신탁사무의 처리상 발생한 채권을 가진 수분양자 등 제3자에 대해서는 수탁자의 고유재산으로도 책임지는 것이 원칙이라는 것이 대법원의 설명이다. 그 원칙을 바꾸는 것이 계약상의 책임한정특약이다.[3,4]

2부 — 직불합의가 있어도 공사대금 청구가 막히는 이유

1. 하도급업체가 이겼던 판결이 대법원에서 뒤집힌 사건

대법원 2023. 6. 29. 선고 2023다221830 판결은 관리형 토지신탁 사업의 하도급대금 직불합의를 다루었다. 신탁사는 공사계약을 승계하였고, 시공사 및 하도급업체와 직접지급에도 합의하였다. 그러나 신탁사업약정은 공사비의 90%를 7순위로, 나머지 공사비를 13순위로 정하였다. 잔여 공사비는 우선수익자의 대출원리금 상환과 신탁사무처리비용 정산 이후 지급하도록 하였다.[2]

직불합의에도 제한이 있었다. 신탁사가 부담하는 금액은 시공사에 지급해야 할 공사대금채무를 초과하지 않고, 시공사에 대하여 주장할 수 있던 사유를 하도급업체에도 주장할 수 있도록 정하였다. 대법원은 하도급대금 직접지급이 발주자에게 원래의 도급대금채무를 넘는 부담을 지우는 제도가 아니라는 점, 발주자는 시행령에 따라 원사업자에 대한 대금지급의무를 한도로 직접지급의무를 부담한다는 점을 들어, 신탁사가 자금집행순서 약정으로 대항할 수 있다고 판단하였다.[2,13]

항소심인 대전고등법원 2023. 2. 8. 선고 2021나16964 판결은 이 제한을 하도급업체에게 그대로 적용할 수 없다고 보았다. 직불합의 때 제시하거나 명시하지 않은 자금집행순서로 지급을 거절하는 것은 하수급인 보호 취지에 맞지 않는다고 판단하였다. 개발이익을 나누어 받지도 않는 하도급업체가 미분양

위험을 떠안고, 분양현황이나 자금집행을 확인할 권한도 없이 지급순서가 돌아왔음을 증명해야 하는 불리함도 지적하였다.[11]

그러나 대법원은 신탁사 패소 부분을 파기환송하였다. 직접지급은 원래의 도급대금채무를 넘는 부담을 지우는 제도가 아니고, 직불합의서도 그 범위와 대항사유를 유지하고 있다는 점을 들어 신탁사의 자금집행순서 주장을 받아들였다.[2] 직불합의가 없어서가 아니라, 직불합의로 취득한 채권에도 원래 채권의 제한이 따라왔기 때문이다. 항소심의 문제의식을 현재의 결론으로 인용할 수는 없다.

공사업체의 입장에서는 신탁사의 서명을 받아 두었는데도, 정작 돈을 받으려면 자기 손에 없는 사업 전체의 장부부터 확인해야 하는 셈이다. 공사를 마쳤다는 증명은 이미 해 놓았는데, 논쟁은 어느새 다른 사람의 대출금이 얼마나 남았는지로 옮겨 간다. 그래서 직불합의서만 제출하는 데서 멈추지 않고 원도급계약과 신탁사업약정, 그 제한이 적용되는 범위를 함께 확인해야 한다.

2. 90%는 언제 받을 돈이고, 나머지 10%는 어떤 돈인가

이 사건에서 대법원은 자금집행순서를 단순한 지급기한으로 보지 않았다. 사업의 성패에 따른 위험을 나누어 부담하고, 선순위 채권에 자금이 집행되지 않은 상태에서는 후순위 채권을 지급하지 않기로 한 정지조건으로 해석하였다. 지급순서가 도래하였다는 사실의 증명책임도 직접지급을 청구하는 하도급업체에 있다고 보았다.[2]

따라서 공사가 끝난 뒤 오래 기다렸다는 주장만으로는 부족하다. 지급시점만 늦추기로 한 계약이라면 더 이상 그 사정이 발생할 수 없게 된 때의 이행 문제를 논할 수 있지만, 그 사정이 생겨야만 지급하기로 한 계약이라면 결과가 달라진다. 자금집행 조항의 성격은 공사계약, 승계계약, 신탁특약의 문언과 우선적용 관계에 따라 개별적으로 정해진다.

실무에서는 청구하는 금액이 어느 순위에 들어가는지부터 나누어 계산할 필요가 있다. 변경계약까지 반영한 원도급대금, 그중 90%의 금액, 이미 지급한 금액과 지급 상대방, 미지급 기성금의 귀속을 대조해

야 한다. 90%가 이미 지급되었다면 나머지 지급조건을 별도로 증명해야 할 수 있다. 내 미수금이 남았다는 사실과 사업 전체의 선지급 한도가 남았다는 사실은 서로 다르다.

3. 현재 잔액이 없다는 답변으로 과거의 지급의무까지 끝나는가

신탁사의 '돈이 없다'는 답변에는 두 내용이 섞일 수 있다. 현재 집행할 재산이 없다는 주장과, 애초에 지급의무가 발생하지 않았다는 주장이다. 지급조건이 충족된 뒤에 자금이 없어진 것이라면 지급의무는 이미 발생한 채로 남는다. 반대로 당시 신탁계좌에 돈이 있었다는 사실만으로 선순위 채권이 남아 있는 후순위 공사비의 지급조건이 충족되었다고 볼 수도 없다.

확인해야 할 시점은 직불합의 체결일, 직접지급청구권 발생일, 기성 승인일, 지급요청일과 문제 된 자금 집행일이다. 대법원도 직접지급청구권이 발생하기 전에 시공사에 대하여 대항할 수 있던 사유와, 발생한 뒤 새로 생긴 사유를 구별한다.[2] 따라서 '지금 90%를 모두 지급했다'는 설명을 들으면 언제, 누구에게, 어떤 채무를 지급했는지를 확인해야 한다. 그 후의 지급이 직접지급채무까지 소멸시켰는지는 별도의 판단이다.

신탁사가 약정된 순서를 어기고 자금을 집행하였다면 그 위반도 구체화해야 한다. 해당 약정이 내 채권을 보호하는 의무인지, 위반이 없었으면 실제로 지급받을 수 있었는지, 손해가 얼마인지가 필요하다. 조건의 성취를 신의성실에 반하여 방해하였다면 민법 제150조에 따른 주장도 검토할 수 있다.[9] 다만 사업 실패나 잔액 부족 자체를 조건성취 방해로 바꾸어 부를 수는 없다. 위반한 집행과 미지급 사이의 연결을 보여 주어야 한다.

3부 — 신탁재산 한도라는 특약을 넘어설 수 있는가

1. 특약은 원칙적으로 유효하다

대법원 2025. 7. 3. 선고 2023다299635 판결에서는 입주 지연을 이유로 분양계약을 해제한 수분양자가 신탁사를 상대로 위약금을 청구하였다. 신탁사는 계약상의 책임한정특약을 주장하였고, 대법원은 신탁재산의 범위 안에서만 책임을 부담한다는 약정이 특별한 사정이 없는 한 유효하다고 판단하였다.[3]

유한책임신탁이라는 별도 제도가 신탁법에 있더라도 이러한 계약상 약정은 효력을 유지한다는 판단도 함께 나왔다. 그러므로 '신탁사가 계약을 위반했으니 자기 돈으로 전부 갚아야 한다'는 주장은 특약 앞에서 멈춘다. 위반에 따른 채무가 발생하였다는 점과, 그 채무를 어떤 재산으로 이행할 책임이 있는지는 구별되기 때문이다.

채권자에게는 실제 회수와 직결되는 제한이다. 신탁사를 상대로 지급판결을 받아도 책임이 해당 신탁재산으로 제한된다면, 신탁사의 다른 사업장 자금이나 고유재산에서 곧바로 받을 수 없다. 유효한 책임한정특약 아래에서는 그 사업의 재산 묶음 안에서 책임을 이행하는 것이다. 신탁사라는 회사는 건재한데, 내가 돈을 받을 사업에는 남은 재산이 없을 수 있다.

수분양자는 분양사무실에서 시행사나 분양대행사와 교섭하였을 뿐, 신탁사 담당자를 직접 만나 본 적도 없는 경우가 있다. 계약서에 적힌 큰 회사의 이름은 안심할 이유처럼 보였지만, 계약이 어긋난 뒤 그 회사를 상대하면 책임은 해당 사업 안에서만 진다는 답이 돌아온다. 그제야 신탁사의 규모와 자신의 채권을 뒷받침하는 재산의 규모가 별개였음을 알게 된다. 책임한정특약의 설명이 중요한 이유도 여기에 있다.

2. 2026년에는 특약을 주장하지 못한 신탁사가 나왔다

대법원 2026. 2. 26. 선고 2023다280945 판결도 오피스텔 입주 지연에 따른 계약 해제와 위약금 사건이다. 공급계약에는 신탁재산과 신탁계약의 업무범위 안에서만 책임진다는 특약이 있었다. 그러나 이번

에는 신탁사가 그 특약에 관한 설명의무를 다하였다고 볼 수 없었다. 대법원은 신탁사가 특약을 계약 내용으로 주장할 수 없다고 본 원심을 유지하였다.[4]

대법원은 책임한정특약을 약관법상 설명하여야 할 중요한 내용으로 보았다. 원래 수분양자에 대하여 고유재산으로도 책임지는 수탁자의 책임을 줄이는 조항이고, 계약 체결 여부에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 신탁업계에서 흔히 쓰는 조항이라는 사정도 충분하지 않았다. 거래 경험이 많지 않고 관리형 토지신탁에 관한 전문지식도 없는 수분양자가 별도 설명 없이 그 제한을 예상하기 어렵다는 점을 들었다.

이 판결은 책임한정특약의 효력 자체를 부정한 것이 아니라, 해당 고객과의 계약에서 이를 주장할 요건을 갖추었는지를 다시 물은 것이다. 계약서에 적혀 있다는 사실과 그 중요한 내용을 설명하였다는 사실을 같은 것으로 처리해서는 안 된다.

3. 설명의무를 다툴 때 필요한 것은 계약 체결 과정이다

수분양자는 계약서 원본뿐 아니라 특약 확인서, 설명자료, 분양상담 문자, 녹취와 계약 당시의 안내문을 확보할 필요가 있다. ‘신탁사가 있으니 안전하다’는 안내와 책임 제한에 관한 설명이 함께 있었는지도 살펴볼 부분이다. 어떤 조항을, 누가, 어느 시점에, 어떤 내용으로 설명하였는지를 특정해야 한다. 단순히 계약서를 읽지 않았다는 주장으로 해결되는 문제는 아니다.

신탁사 측이 설명 확인란의 서명을 제시하면 그 문구와 실제 설명을 대조해야 한다. 반대로 개별 교섭으로 책임 범위를 정하였거나, 고객이 제한 내용을 이미 구체적으로 알고 있었다면 설명의무 주장은 달라질 수 있다. 약관인지 여부, 개별 합의의 유무, 고객의 예측가능성과 설명 사실을 각각 검토해야 한다.

공사업체가 이 판결을 원용하려면 수분양자와의 차이를 먼저 넘어야 한다. 신탁사업약정의 당사자로 참여하고 자금집행순서를 협의한 시공사는, 정형화된 공급계약을 체결한 수분양자와 같은 예측가능성 기준을 적용받기 어렵다. 하도급업체 역시 자신의 직불합의가 약관인지, 원래 채권에 붙은 제한을 어떤 경

위로 받아들였는지를 확인해야 한다. ‘신탁사업을 해 본 업체’라는 이유만으로 모든 설명이 면제되는 것도, 수분양자 판결이라는 이유로 모든 특약을 배제할 수 있는 것도 아니다.

2026년 판결은 지급순서 주장에서도 참고할 만하다. 대법원은 그 사건의 위약금 이행기가 계약 해제 통지의 도달과 함께 도래하며, 신탁사무처리비용을 모두 변제한 뒤에야 도래하는 것은 아니라고 본 원심도 유지하였다.[4] 2023년 공사대금 사건의 순위 약정을 모든 분양계약상의 위약금에 옮길 수는 없다. 내부 신탁계약의 집행순서가 내가 체결한 계약의 지급조건이 되었는지를 따로 확인해야 한다.

4부 — 시행사를 통한 계약은 어디까지 신탁사를 구속하는가

1. 계약 체결권한과 조건 변경권한, 대금 수령권한을 나누어 본다

분양상담과 계약서 작성, 조건 협의와 대금 안내는 시행사나 분양대행사가 맡고, 부동산의 등기명의자는 신탁사인 사업이 있다. 통상적인 분양에서는 이 역할 분담이 드러나지 않다가, 할인이나 별도 특약을 약속하였거나 기존 채무와 분양대금을 상계하였을 때 문제가 생긴다. 시행사와 합의하였다는 사실만으로 신탁사도 그 조건을 받아들였다고 할 수 있는가가 쟁점이다.

먼저 계약당사자와 대리관계를 확인해야 한다. 시행사가 자기 이름으로 타인의 권리를 매매하였더라도 매수인과의 계약은 유효하게 성립한다. 민법 제569조에 따르면 매도인은 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 의무를 진다.[9] 그러나 그 의무는 시행사의 의무이지 신탁사의 의무로 바뀌지는 않는다. 신탁사가 매도인인지, 시행사가 신탁사의 대리인으로 계약하였는지, 신탁해지와 반환을 요구할 다른 권리가 있는지를 밝혀야 한다.

분양업무를 맡겼더라도 권한의 범위는 따로 확인할 문제이다. 정해진 조건으로 계약할 권한과 분양가격을 바꾸거나 별도 특약을 붙일 권한, 대금을 다른 계좌로 받을 권한은 나누어 확인해야 한다. 계약서가 신탁해지 후 소유권이전을 예정한다면 해지의 요건과 주체도 살펴야 한다. 매수인의 완납 사실만으로 우선수익자의 권리와 신탁사의 등기의무가 모두 정리되지는 않는다.

2. 신탁사의 직인이 찍힌 계약서가 효력을 가진 사건

대법원 2002. 3. 15. 선고 2000다52141 판결에서는 시행사 측이 자신의 채무를 갚는 대신 신탁된 아파트 8세대를 제공하였다. 신탁사는 시행사에 그와 같은 대물변제 권한이 없다고 주장하면서 수분양자 지위의 부존재 확인 등을 청구하였다.[5]

대법원은 시행사에게 자기 채무를 신탁재산으로 갚을 실제 대리권이 있었다는 해석은 받아들이지 않았다. 그러나 표현대리는 인정하였다. 신탁사가 공동매도인으로 기재된 공급계약서에 대표이사의 직인을 찍어 일괄 교부하였고, 시행사 측이 독자적으로 계약을 체결하고 분양대금도 직접 받아 온 사정 등이 있었다. 상대방이 시행사에게 그 형태의 계약을 체결할 권한이 있다고 믿을 정당한 이유가 있다는 것이다. 신탁사의 상고는 기각되었다.

표현대리가 인정된 근거는 분양업무의 실제 위임과 신탁사가 만들어 준 외관, 그리고 그 권한을 믿을 상대방의 정당한 이유였다. 시행사를 통한 모든 계약에 신탁사가 책임진다는 판결로 읽을 수 없는 이유이다. 신탁사가 승인한 계약서인지, 직인을 누가 어떻게 교부하였는지, 종전 계약과 대금 수령이 어떤 방식으로 이루어졌는지를 확인해야 한다. 할인이나 대물변제, 상계와 같은 특별한 조건에서는 그 조건까지 허용할 권한이 있었는지 또는 그렇게 믿을 근거가 있었는지를 따로 대조해야 한다.

계약서가 위조되었거나 신탁사의 명시적인 거절을 알면서 거래한 경우라면 보호받을 외관 자체가 없다. 반대로 계약서에 수납계좌가 적혀 있다는 사정 하나만으로 표현대리 논의가 끝나는 것도 아니다. 2002년 사건에서도 분양대금 수령권에 관한 기재가 있었지만 전체 거래 경위에 따라 표현대리가 인정되었다. 계약서의 문구와 신탁사가 허용한 실제 운영을 함께 보되, 문제 된 계약조건과 권한의 외관이 서로 맞닿아 있는지를 밝혀야 한다.

3. 지정계좌를 벗어난 대금 지급으로 등기 청구가 막힌 사건

대법원 2010. 12. 9. 선고 2009다81289 판결에서는 상가 수분양자들이 신탁 일부해지와 소유권이전을 요구하였으나 받아들여지지 않았다. 해당 사업은 지정된 수납계좌를 통해 분양대금으로 대출금과 공사대금을 변제하는 구조였는데, 수분양자들이 그 계좌로 대금을 입금하지 않았다.[6]

대법원은 유효한 분양계약이 이루어지고 분양대금으로 우선수익자의 채권 변제가 확보된 상태라면, 시행사의 일부해지와 우선수익자의 동의에 관한 묵시적 약정을 인정할 수 있다고 보았다. 그러나 그 사건에서는 지정계좌 입금이 이루어지지 않아 요건이 충족되지 않았다고 판단하였다. 시행사에 돈을 다 주었다는 사실과 신탁 구조 안에서 해지·이전 요건이 갖추어졌다는 사실은 달랐던 것이다.

대금 지급에서도 영수증과 자금의 이동 경로를 함께 보아야 한다. 시행사나 분양대행사에게 지급한 돈이 실제로 지정계좌에 들어갔는지, 해당 호실의 신탁해지에 필요한 채무가 상환되었는지, 권한 있는 자가 별도 수령이나 상계 방식을 승인하였는지를 확인해야 한다. 현장에서 인정받은 완납과 신탁 구조 안에서의 완납이 어긋나면, 매수인은 등기 대신 시행사에 대한 반환청구만 남는 상황에 놓일 수 있다.

5부 — 돈을 받았다는 사실과 자신의 위법행위에 대한 책임

1. 신탁사 계좌로 보냈으니 신탁사가 반환하라는 주장도 막힐 수 있다

분양대금을 신탁사의 지정계좌에 넣었다고 하여, 계약 해제나 취소 때 신탁사에 곧바로 반환을 청구할 수 있는 것도 아니다. 대법원 2017. 7. 11. 선고 2013다55447 판결에서는 시행사가 분양대금채권을 신탁사에 양도하였고, 이를 승낙한 수분양자들이 신탁사 계좌로 대금을 지급하였다.[7]

대법원은 이를 수분양자와 시행사, 시행사와 신탁사 사이의 이행을 한 번의 지급으로 처리하는 단축급부로 보았다. 신탁사는 시행사와의 계약관계에 따라 돈을 수령하였으므로, 수분양자가 시행사와의 계약에 하자가 있다는 이유만으로 신탁사에 직접 부당이득반환을 청구할 수는 없다는 것이다. 돈은 신탁사 계좌에 들어갔지만 반환채무는 시행사에 남은 것이다.

다만 주문은 원고 전부 패소로 끝나지 않았다. 원심이 예비적 청구의 일부를 인용한 부분은 원고들만 상고하였기 때문에 불이익변경금지에 따라 유지되었다. 대법원이 제시한 부당이득 법리와 실제 주문의 결과를 구분하여 읽어야 한다.[7]

이 법리를 적용할 때에는 신탁사의 지위를 먼저 확인해야 한다. 신탁사가 매도인으로 계약을 체결하였다면 계약상 반환의무를 지고, 분양대금채권의 양수인이나 자금관리자로 수령하였을 뿐이라면 단축급부 법리가 적용된다. 어느 쪽의 결론도 다른 쪽에 옮겨 쓸 수 없다.

2. 압류를 무시하고 등기를 넘긴 신탁사는 손해배상책임을 졌다

대법원 2018. 12. 27. 선고 2018다237329 판결은 신탁사 자신의 행위에 책임을 물은 사례이다. 채권자는 위탁자가 신탁사에 대하여 가지는 신탁수익청구권에 압류 및 추심명령을 받았고, 그 명령은 신탁사에 송달되었다. 그런데 이후 위탁자와 우선수익자의 요청으로 신탁사는 오피스텔 소유권을 매수인들에게 직접 이전하였다.[8]

신탁사는 신탁계약에 따른 처분이라고 주장하였지만, 대법원은 해당 특약을 신탁 종료 후 위탁자에게 반환하고 다시 매수인에게 이전하는 절차를 줄이기 위한 조항으로 해석하였다. 신탁사가 독립적인 처분권한에 따라 매각한 것이 아니라, 압류된 위탁자의 반환청구권을 이행한 것이라는 판단이다. 압류의 효력이 그 신탁원본의 급부청구권에도 미쳤으므로, 신탁사의 이전등기는 압류를 위반한 불법행위가 되었다. 신탁사의 손해배상책임을 인정한 원심은 유지되었다.

여기서 채권자가 확보한 것은 '신탁사가 사업을 잘 관리했어야 한다'는 추상적인 주장이 아니었다. 특정 권리에 대한 압류, 신탁사에 대한 송달, 그 이후의 구체적인 이전등기와 해당 특약의 의미가 연결되어 있었다. 위탁자에 대한 채권으로 시작하였지만, 신탁사의 후속 위법행위가 별도의 손해배상청구 근거가 된 것이다.

3. 자금관리 잘못을 주장하려면 누구에 대한 의무인지 밝혀야 한다

수익권 압류가 신탁사의 처분을 어디까지 막는지는 2018년 사건의 사실관계가 그 한계를 보여 준다. 그 사건에서 책임이 인정된 것은 이전등기가 압류된 반환청구권의 이행에 해당하였기 때문이다. 신탁계약에 따라 수탁자가 독립적으로 처분하는 경우에도 같은 결론이 나는지는 처분권한과 압류 대상에 따라 다시 판단해야 한다.

또한 신탁사가 시행사의 잘못을 막지 못하였다는 사정은 손해배상의 출발점일 뿐 근거가 되지 못한다. 2017년 분양대금반환 사건에서도 신탁사가 시행사의 사기에 가담하였다는 점이나 관련 주의의무 위반을 인정할 증거가 없었고, 계약상 주의의무 위반이 있더라도 곧바로 수분양자에 대한 손해배상책임이 생기는 것은 아니라고 판단하였다.[7]

자금 유출이나 무단 분양을 문제 삼으려면 신탁사가 어떤 의무를 위반하였는지, 그 의무가 해당 채권자를 보호하는 것인지, 위반이 없었다면 회수할 수 있었던 금액이 얼마인지를 제시해야 한다. 단순한 미수금을 불법행위 손해배상으로 바꾸어 청구한다고 책임한정특약이 저절로 사라지지는 않는다. 특약의 적용 범위와 별도 불법행위의 성립을 각각 다투어야 한다.

6부 — 소송과 함께 무엇을 확보할 것인가

1. 수익권을 묶어도 시행사에게 남을 몫이 생기지는 않는다

신탁법 제22조는 신탁재산에 대한 강제집행과 보전처분을 원칙적으로 금지하지만, 신탁 전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우에는 예외를 둔다.[1] 다만 신탁 전에 공사를 하였거나 해당 건물에 공사비가 들어갔다는 사실만으로 예외가 충족된다고 보아서는 안 된다. 채권의 발생 원인과 채무자, 신탁과의 관계를 밝혀야 한다.

신탁사에 대한 공사대금채권 등이 있고 예외 요건에 해당한다면 해당 신탁재산에 대한 보전을 검토할 수 있다. 신탁사의 고유재산을 대상으로 할 수 있는지는 책임한정특약의 효력과 범위까지 확인해야 한다. 반면 시행사에 대해서만 채권이 있다면 신탁사 명의의 부동산을 시행사의 재산으로 가압류할 수는 없다. 시행사의 신탁수익권이나 신탁 종료에 따른 반환청구권이 보전 대상인지 검토하는 방식으로 방향이 바뀐다.

문제는 보전할 권리를 찾은 다음이다. 미분양이 이어지고 대출이자와 비용이 누적된 사업에서는 시행사의 수익권이 법적으로 존재하더라도 실제로 받을 몫은 없을 수 있다. 현장에 건물이 남아 있으니 회수할 재산도 있다고 생각하기 쉽지만, 시행사에게 돌아올 몫은 건물의 가치에서 선순위 채무와 비용을 뺀 나머지이다. 수익권을 묶는 결정은 남을 몫을 보전할 뿐, 이미 사라진 몫을 만들어 주지는 않는다.

대법원 2021. 6. 10. 선고 2017다254891 판결은 이 문제를 사해행위취소 사건에서 보여 준다. 시행사는 신탁된 오피스텔 일부를 하도급업체들에게 미지급 공사비 대신 넘겼고, 시행사에 대한 공사대금채권자가 그 처분을 다투었다. 그러나 당시 남아 있던 부동산의 가치보다 우선수익자의 채권액이 훨씬 커 시행사의 후순위 수익권에는 적극재산으로서의 가치가 없었다. 대법원은 처분으로 일반채권자의 공동담보가 감소하였다고 볼 수 없다는 이유로 사해행위 주장을 받아들이지 않은 원심을 유지하였다.[12]

그 판결은 후순위 수익권을 부동산 시가 그대로 평가해서는 안 된다고 설명한다. 신탁 종료 때 예상되는 재산가액에서 비용과 신탁보수, 우선수익자에 대한 채무를 공제하고, 남을 금액을 당시의 현재가치로 평가하여야 한다는 것이다.[12] 압류 사건은 아니지만, 압류하려는 권리에 회수할 가치가 있는지를 볼 때도 이 계산이 출발점이 된다. 취소소송을 더하더라도 그 계산의 결과는 바뀌지 않는다.

부동산 자체의 이전을 청구할 권리가 있다면 처분금지가처분도 검토할 수 있다. 그러나 금전채권을 보전하려는 채권자에게 신탁사의 분양이나 처분 전체를 막을 권리는 없다. 가압류로 보전할 금전채권인지,

가처분으로 보전할 특정 부동산에 관한 권리인지에 따라 신청의 근거와 대상이 달라진다. 잘못된 대상을 묶는 동안 실제로 남아 있던 자금이 집행될 수 있다.

2. 잔여가치의 계산과 신탁사에 대한 직접 청구를 따로 확인한다

회수 가능성을 계산할 때에는 미분양 호실의 최초 분양가를 그대로 합산해서는 곤란하다. 실제 처분이 가능한 가격과 소요기간, 그동안 늘어날 이자와 보유·처분비용을 함께 보아야 한다. 예컨대 처분예상액이 100억 원이어도, 약정에 따라 먼저 지급할 채무와 비용이 110억 원이라면 후순위 시행사에게 돌아올 금액은 없다. 미분양 호실이 많다는 말만으로 그 수익권의 가치가 크다고 할 수 없는 이유이다.

다만 신탁사가 제시한 정산 예상액을 그대로 받아 적을 필요도 없다. 우선수익권의 한도금액과 현재 지급받을 채권액을 구별하고, 실제 대출잔액과 상환내역, 이자 산정기간, 비용의 발생 근거 및 적용 순위를 확인해야 한다. 이미 갚은 채무가 남은 것으로 계산되었거나, 같은 금액이 중복 반영되었거나, 신탁보수가 약정과 달리 증액되었거나 비용의 발생 근거가 불분명하다면 잔여가치 계산의 전제부터 다툴 수 있다. 어떤 금액을 얼마까지 먼저 지급하는지는 해당 신탁약정에 따라 판단할 문제이다.

또 시행사의 수익권이 비어 있더라도 나의 신탁사에 대한 청구는 따로 남을 수 있다. 신탁사가 직접 부담한 공사대금이나 분양계약상 채무가 있는지, 그 채권에 어떤 지급조건과 책임한정이 붙는지를 다시 확인해야 한다. 이미 발생한 지급의무를 단순히 잔여수익이 없다는 이유로 부정하는 것인지, 실제로 선순위 변제가 조건인 채권인지를 구별하는 것이다. 설명의무 위반으로 책임한정특약을 주장할 수 없거나 신탁사 자신의 위법행위에 대한 책임이 성립하는 경우에도 청구의 근거와 집행재산을 따로 검토해야 한다.

우선수익권을 직접 가진 채권자는 자신의 권리가 침해되었는지도 별도로 살펴야 한다. 2021년 판결 역시 문제 된 이전이 선순위권리자의 수익권을 침해하여 이루어졌다는 점을 지적하면서도, 일반채권자로서 시행사의 책임재산을 회복시키려는 사해행위 주장은 받아들이지 않았다.[12] 같은 처분이라도 누구

의 어떤 권리를 근거로 다투는지에 따라 달라진다. 반면 시행사에 대한 일반채권만 있고, 실제 잔여가치도 없으며, 신탁사의 별도 의무 위반도 없다면 수익권 압류를 해결책처럼 설명하기는 어렵다.

3. 계약서보다 넓게, 필요한 쟁점보다 좁게 자료를 확보한다

공사대금 사건의 기본 자료는 공사계약과 변경계약, 신탁계약 본문·특약, 사업약정과 자금집행순서표, 계약 승계서, 직불합의서이다. 여기에 기성 승인과 지급요청, 신탁사의 회신을 날짜순으로 붙인다. 신탁사가 90%를 이미 지급하였다고 한다면 총액만 요구할 것이 아니라 지급일, 상대방, 근거 채무와 누계가 나타나는 집행내역을 요구해야 한다. 선순위 변제가 조건이라면 관련 대출잔액과 상환·정산 자료가 필요하다.

분양 사건에서는 계약서에 기재된 매도인과 서명 자격, 신탁원부, 분양업무 위임과 계약조건 승인, 지정계좌와 실제 입금계좌를 확인한다. 표현대리를 주장하려면 신탁사가 교부한 계약서와 종전의 거래 방식을, 책임한정특약의 설명의무를 다투려면 계약 체결 과정과 설명 확인자료를 확보한다. 같은 분양계약서라도 다투는 청구에 따라 필요한 증거가 달라진다.

상대방이 자료를 내놓지 않으면 소송에서 문서제출명령이나 사실조회 등을 활용할 수 있다. 문서제출명령은 민사소송법상 제출의무가 있는 문서를 대상으로 하는 절차이므로, 어느 기간의 어떤 집행내역이 지급조건이나 채무소멸을 증명하는지, 어떤 잔액과 비용이 수익권의 가치를 좌우하는지, 그 자료를 누가 보유하고 있는지를 특정해야 한다.[10] 자료가 신탁사 안에 있다는 사정만으로 조건성취의 증명책임이 자동으로 바뀌는 것도 아니다.

맺음

이 글에서 본 대법원 판결을 결론과 그 결론을 가른 지점으로 정리하면 다음과 같다. 청구가 인정된 사건에는 각기 다른 근거가 있었고, 받아들여지지 않은 사건은 근거가 없어서가 아니라 그 근거에 붙은 제한을 넘지 못했다.

판결	쟁점과 결론	결론을 가른 지점
신탁사에 대한 청구가 인정된 사건		
대법원 2026. 2. 26. 2023다280945	책임한정특약의 약관법상 설명의무 — 설명을 다하지 않은 신탁사는 특약을 계약 내용으로 주장할 수 없음. 위약금 이행기는 해제통지 도달 시	특약의 효력이 아니라 해당 고객에게 설명한 사실
대법원 2002. 3. 15. 2000다52141	시행사가 자기 채무의 대물변제로 체결한 분양계약 — 실제 대리권은 부정, 권한을 넘은 표현대리는 인정	직인 날인 계약서의 일괄 교부와 시행사가 독자적으로 계약·수금해 온 종전 거래 방식
대법원 2018. 12. 27. 2018다237329	수익청구권 압류 송달 후 매수인 앞 직접 이전등기 — 압류 위반 불법행위, 신탁사의 손해배상책임	특정 권리의 압류와 송달 뒤에 이루어진 신탁사 자신의 후속 행위
청구 또는 주장이 받아들여지지 않은 사건		
대법원 2023. 6. 29. 2023다221830	직불합의가 있어도 신탁사는 자금집행순서로 대항 가능. 자금집행순서는 정지조건이고 성취의 증명책임은 하도급업체에 있음	직불합의로 취득한 채권에 원래 채권의 제한이 그대로 따라옴
대법원 2025. 7. 3. 2023다299635	관리형 토지신탁 수탁자의 책임한정특약은 원칙적으로 유효. 유한책임신탁 제도의 존재는 효력을 부정할 사유가 아님	계약 위반에 따른 채무의 발생과 그 채무를 이행할 재산의 범위
대법원 2010. 12. 9. 2009다81289	지정 수납계좌 밖으로 분양대금을 지급한 수분양자의 신탁 일부해지·소유권이전 청구 기각	시행사에 돈을 다 준 사실과 신탁 구조 안에서 해지·이전 요건이 갖추어진 사실
대법원 2017. 7. 11. 2013다55447	신탁사 계좌에 입금한 분양대금의 해제·취소에 따른 반환청구 — 단축급부로서 신탁사에 대한 직접 부당이득반환 불가	돈을 받은 자와 그 돈을 반환할 채무자
대법원 2021. 6. 10. 2017다254891	시행사가 신탁을 종료하고 하도급업체에 대물변제한 처분의 사해행위취소 청구 기각	후순위 수익권의 가치 — 시가가 아니라 선순위 채무·비용을 공제한 잔여가치

소송 전에 정리할 것은 세 가지이다. 자기 청구의 근거, 그 근거에 붙은 제한, 그리고 청구가 인정될 때 실제로 돈을 받을 재산이다. 신탁사가 서명한 서류와 신탁사 명의의 부동산은 청구의 출발점이지 종착점이 아니다. 시행사의 수익권을 찾아낸 것과 회수할 자금을 찾아낸 것은 끝까지 구별해야 한다.

참고 판례 및 법령

[1] 신탁법 제2조, 제22조, 제38조 — 신탁의 구조, 신탁재산에 대한 강제집행·보전처분의 제한과 예외, 수익자에 대한 수탁자의 유한책임.
신탁법 제22조 · 국가법령정보센터
[2] 대법원 2023. 6. 29. 선고 2023다221830 판결 — 하도급대금 직접지급청구권의 범위, 발주자의 대항사유, 자금집행순서의 정지조건성과 증명책임. 신탁사 패소 부분 파기환송.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[3] 대법원 2025. 7. 3. 선고 2023다299635 판결 — 관리형 토지신탁 수탁자의 책임한정특약의 원칙적 유효성. 쌍방 상고 모두 기각.
대법원 공개 판결요지 및 판결문

[4] 대법원 2026. 2. 26. 선고 2023다280945 판결 — 책임한정특약에 관한 약관법상 설명의무, 미이행 시 계약 내용으로 주장할 수 없는 효과, 위약금의 이행기. 신탁사의 상고 기각.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[5] 대법원 2002. 3. 15. 선고 2000다52141 판결 — 신탁부동산의 소유권, 시행사의 대물변제에 관한 실제 대리권과 표현대리의 구별. 신탁사의 상고 기각.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[6] 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009다81289 판결 — 우선수익자 변제 확보를 전제로 한 신탁 일부해지·동의의 묵시적 약정, 지정 수납계좌 밖의 지급. 수분양자들의 상고 기각.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[7] 대법원 2017. 7. 11. 선고 2013다55447 판결 — 삼각관계의 단축급부와 직접 부당이득반환청구, 신탁사의 별도 손해배상책임. 원고들만의 상고로 예비적 청구 일부 인용 부분은 불이익변경금지에 따라 유지.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[8] 대법원 2018. 12. 27. 선고 2018다237329 판결 — 신탁수익청구권 압류의 신탁원본 급부청구권에 대한 효력, 직접 이전등기의 법적 성격, 압류 위반에 따른 수탁자의 불법행위책임. 신탁사의 상고 기각.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[9] 민법 제126조, 제150조, 제569조, 제750조 — 권한을 넘은 표현대리, 조건성취 방해, 타인의 권리 매매, 불법행위의 기본 규정.
민법 · 국가법령정보센터
[10] 민사소송법 제344조, 제345조 — 문서 제출의무와 문서제출명령 신청의 특정.
민사소송법 제344조 · 국가법령정보센터
[11] 대전고등법원 2023. 2. 8. 선고 2021나16964 판결 — 직불합의 당시 고지되지 않은 자금집행순서, 하도급업체의 정보 접근과 개발위험 부담에 관한 판단. 신탁사 패소 부분은 대법원 2023다221830 판결로 파기환송.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[12] 대법원 2021. 6. 10. 선고 2017다254891 판결 — 후순위 신탁수익권의 가치평가와 신탁 종료를 거친 처분의 사해행위 해당 여부, 일반채권자의 공동담보와 선순위 수익권 침해의 구별. 공사대금채권자의 상고 기각.
판결 전문 · 국가법령정보센터
[13] 하도급거래 공정화에 관한 법률 제14조, 같은 법 시행령 제9조 제3항 — 발주자의 하도급대금 직접지급의무의 발생 사유와 그 한도(원사업자에 대한 대금지급의무의 범위).
하도급법 제14조 · 국가법령정보센터
하도급법 시행령 제9조 · 국가법령정보센터

압수된 휴대폰을 돌려받는 법

> *증거와 범행 도구의 구별부터 환부와 가환부 그리고 수감 중 수령까지*

0. 도입

휴대폰 없이 하루를 보내는 일은 생각보다 어렵다. 업무 연락과 은행 거래, 가족과 주고받는 안부까지 작은 기기 하나를 거친다. 그 안에는 당사자가 기억하지 못하는 대화와 사진, 이동과 거래의 흔적도 쌓인다. 휴대폰은 생활에 필요한 물건인 동시에, 그 사람이 어떤 생활을 해 왔는지 보여주는 기록이기도 하다.

경찰이 피의자의 휴대폰에 관심을 갖는 이유도 여기에 있다. 누구와 연락했고, 어떤 지시를 받았으며, 돈이 어디로 흘렀는지를 확인할 단서가 한곳에 모여 있다. 조사실에서는 모른다고 답한 사람과 주고받은 메시지가 남아 있을 수 있고, 단순한 심부름이었다는 설명의 진위도 그 대화에서 드러날 수 있다.

그런데 정작 휴대폰을 빼앗긴 사람의 관심은 다른 곳에 가 있기도 하다. 보이스피싱이나 전자금융거래법 위반 사건의 말단 가담자 중에는 자신이 어떤 일에 가담했고 어느 정도의 처벌을 받을 수 있는지보다 “제 폰은 언제 주나요”를 먼저 묻는 사람이 있다. 구속과 실형은 아직 실감이 나지 않지만, 당장 폰이 없는 불편은 선명한 것이다. 자신의 역할과 책임부터 설명해야 할 자리에서 그 질문만 되풀이하면, 아직 사태 파악을 못 하고 있다는 인상부터 남기기 쉽다.

상선의 지시를 받고 하선에게 업무를 전달하던 휴대폰이라면 반환도 간단하지 않다. 조직의 연락망을 보여주는 증거이면서 범행에 사용된 도구이기 때문이다. 포렌식만 끝나면 돌려받을 것으로 생각했는데

재판이 끝날 때까지 맡겨 두어야 할 수도 있고, 판결에 몰수가 붙을 수도 있다. 휴대폰을 찾기 전에 주인이 먼저 교도소로 가는 경우도 생긴다.

그렇다고 압수된 휴대폰은 모두 재판이 끝날 때까지 기다려야 하거나, 범행에 한 번 사용했다는 이유만으로 영영 돌려받지 못하는 것은 아니다. 무엇 때문에 압수하고 있는지에 따라 반환을 요구할 근거와 절차가 달라진다. 이 글에서는 그 구별부터 시작하여, 임의제출과 소유권 포기, 환부·가환부 신청, 수감 중 실제 수령까지 살펴본다.

1부 — 압수된 폰과 몰수된 폰

1. 경찰이 가져간 것과 끝내 돌려주지 않는 것은 다르다

경찰이 휴대폰을 압수했다는 것은 수사와 재판에 필요하여 기기를 확보했다는 뜻이다. 그 순간 소유권까지 국가에 넘어가는 것은 아니다. 압수한 목적이 달성되어 더 보관할 필요가 없어지면 돌려주는 것이 원칙이다. 반면 몰수는 판결로 물건의 소유를 박탈하는 형벌이다. 휴대폰의 몰수가 확정되면 수사가 끝났으니 돌려달라는 요구로 해결할 수 없다.[1][2][3]

압수는 증거를 확보할 목적으로도, 나중에 몰수할 물건을 확보할 목적으로도 할 수 있다. 가령 사건 뒤 친구에게 보낸 대화가 저장되어 있어 폰을 가져갔다면, 필요한 대화를 확보한 뒤에도 기기 자체가 계속 필요한지를 따져볼 수 있다. 반면 그 폰으로 피해자에게 사기 전화를 걸거나 조직의 범행 지시를 주고받았다면, 대화를 복제한 뒤에도 범행 도구인 기기를 몰수할 것인지가 남는다.[1][2]

따라서 돌려받으려는 쪽의 주장도 달라진다. 증거 확보가 목적이라면 자료를 복제해 두었는데 원물까지 계속 보관할 이유가 있는지를 묻는다. 몰수까지 문제 된다면 실제로 범행에 사용한 기기인지, 기기 전체를 몰수할 정도의 관련성과 필요성이 있는지를 다투어야 한다. 단순히 “포렌식이 끝났다”는 말로 두 문제를 한꺼번에 해결할 수는 없다.

2. 환부와 가환부는 효과가 다르다

환부는 계속 압수할 필요가 없는 물건을 돌려주는 것이다. 가환부는 증거로 쓸 물건 등을 잠정적으로 돌려주는 것으로, 다시 제출해야 할 가능성이 남는다. 재판 중에는 형사소송법 제133조가, 기소 전 수사 단계에서는 제218조의2가 기본적인 신청 근거가 된다.[3][4]

가환부를 받았다고 몰수 가능성까지 사라지는 것은 아니다. 재판부가 기기를 계속 보관할 필요가 없다고 보아 일단 돌려주더라도, 최종 판결에서 범행과의 관련성을 판단하여 몰수를 선고할 수 있다. 가환부 결정과 몰수 여부는 각각 확인해야 한다.

휴대폰 기기와 그 안의 전자정보도 구별해야 한다. 기기를 돌려받아도 수사기관이 적법하게 확보한 대화와 복제자료가 함께 없어지는 것은 아니다. 반환 이후에도 그 자료는 증거로 사용될 수 있다. 휴대폰 환부를 받아내는 일과 포렌식 자료의 증거능력을 다투는 일은 주장과 절차가 다르다.

3. 임의제출도 압수의 한 방법이다

영장을 들고 가져가는 경우만 압수인 것은 아니다. 소유자·소지자·보관자가 자발적으로 제출한 물건은 형사소송법 제218조에 따라 영장 없이 압수할 수 있다. “수사에 협조하려고 내가 건넸다”는 사정만으로 경찰이 잠시 빌린 물건이 되는 것은 아니다. 임의제출에 따라 압수되었다면, 돌려받을 때에도 압수를 계속할 필요가 있는지와 환부·가환부 요건을 따지게 된다.[5]

임의제출과 소유권 포기는 별개의 의사표시이다. 폰을 제출한다는 말이 곧 폰의 소유권을 버린다는 뜻은 아니다. 다만 경찰의 범죄수사규칙은 임의제출한 사람이 소유권도 포기한다는 의사를 표시하면 그 취지를 임의제출서에 적거나 별도의 소유권포기서를 받도록 한다. 서류의 제목만 보고 수사에 협조하는 내용이라고 생각할 일이 아니다. 기기를 나중에 돌려받을 생각이라면 제출하는 물건과 포기 문구를 확인하고, 반환받겠다는 의사를 분명히 해 두어야 한다.[6]

이미 제출한 뒤라면 압수목록을 확보하고, 자신이 작성한 임의제출서에 소유권 포기 문구가 있는지부터 확인한다. 기기 제출, 저장된 정보의 제출 범위, 기기 소유권의 포기는 서로 다른 문제이다. 반환을 요구할 때에는 어느 기기를 어떤 경위로 제출했고 계속 돌려받기를 원하는지 구체적으로 적는 편이 좋다.

4. 소유권 포기서를 썼다고 환부청구까지 끝나는 것은 아니다

소유권 포기서를 썼다는 이유로 반환이 불가능하다는 답변을 받았다면, 대법원 1996. 8. 16.자 94모51 전원합의체 결정을 확인할 필요가 있다. 대법원은 소유권을 포기하여 실체법상 권리를 잃었다고 하더라도, 그 사정이 형사소송법상 환부청구권에 영향을 미치지는 않는다고 보았다. 환부청구권 자체를 포기한다는 의사표시도 효력이 없다고 판단했다.[7]

압수물을 돌려주는 절차는 압수 전의 상태를 회복하는 절차이다. 물건의 민사상 소유자가 누구인지를 최종 확정하는 재판과는 다르다. 따라서 소유권 포기서가 있다는 사정만으로, 더 압수할 필요가 없는 물건을 돌려줄 의무까지 없어지는 것은 아니다. 이를 소유권 포기서의 모든 효력이 사라진다는 뜻으로 읽어서도 안 된다.[7]

실제로 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000다27725 판결에서는 수사 중 압수물의 소유권 포기 확인서를 작성했던 당사자들이, 몰수 선고 없이 형사판결이 확정된 뒤 국가를 상대로 물건의 인도를 청구했다. 대법원은 포기 확인서 때문에 환부청구권이 소멸하는 것은 아니라고 보아 반환을 명한 원심을 유지했다. 포기서를 썼다는 답변만 듣고 멈출 일은 아니라는 뜻이다.[8]

다만 포기서의 존재만으로 반환을 거절할 수 없다는 것과, 지금 당장 반환해야 한다는 것은 다른 문제이다. 필요한 증거조사가 남아 있거나 몰수 여부를 심리 중이라면 그 보관 사유도 함께 다투어야 한다. 신청서에는 포기서에 관한 법리와 현재 기기를 계속 보관할 필요가 없다는 사정을 함께 적어야 한다.

2부 — 포렌식이 끝났다는 말의 의미

1. 포렌식 완료와 환부는 별개의 처분이다

휴대폰에서 필요한 대화와 파일을 확보했다면 기기 자체를 계속 보관할 필요가 줄어든다. 형사소송법 제218조의2는 사본을 확보한 경우 등을 환부·가환부 판단에 연결한다. 재판 단계의 제133조 제2항은 증거 확보만을 목적으로 압수한 물건으로서 소유자나 소지자가 계속 써야 하는 물건에 대하여, 원형을 보존하는 조치를 하고 신속히 가환부하도록 정한다.[3][4]

다만 포렌식이 끝났다고 하여 환부가 저절로 뒤따르지는 않는다. 포렌식은 수사관이 기기에서 자료를 추출하는 작업이고, 환부는 수사기관이 그 기기를 더 보관하지 않기로 정하는 별도의 처분이다. 신청이 없으면 두 번째 처분은 시작되지 않는다. 수사기관으로서는 기기를 계속 보관하여 잃을 것이 없고, 돌려준 뒤 추가 확인이 필요해지면 그 책임을 지게 된다. 그대로 두면 송치할 때 기기도 함께 넘어가고, 재판이 끝날 때까지 압수물 창고에 남는다.

‘포렌식 완료’라는 말에도 두 단계가 섞여 있다. 저장매체를 통째로 복제하는 이미징이 끝난 것과, 복제본에서 사건과 관련된 정보만 선별하여 압수하고 그 목록을 교부한 것은 다르다. 기기를 사본으로 대체할 수 있게 되는 시점은 후자이다. 따라서 당사자에게 확인할 것은 포렌식이 끝났는지가 아니라 전자정보 압수목록을 받았는지이다. 받았다면 그날 환부·가환부를 신청할 수 있다. 받지 못했다면 선별이 끝나지 않았거나, 끝났는데도 목록을 교부하지 않은 것이므로 목록의 교부부터 요구해야 한다.[5]

신청 이유에는 휴대폰이 생활필수품이라는 사정을 구체적으로 적는다. 업무 연락, 고객 관리, 금융 인증, 가족과의 연락 등에 계속 사용해 왔고, 필요한 자료는 별도로 확보되어 있다는 점을 함께 제시한다. ‘비싼 폰이니 빨리 달라’는 말은 사정이 되지 않는다. 기기를 보관하지 않아도 증거를 유지할 수 있는 이유가 중요하다.

수사기록 전체를 볼 수 없는 단계라면 분석 완료일과 자료 확보 범위를 아는 사실인 것처럼 써서는 안 된다. 확인된 경과를 적고, 나머지는 담당자에게 확인을 요청한 사항으로 제시한다. 증거 확보 외에 몰수를 위해 보관하는 것인지도 이때 함께 묻는다.

2. 폰이 두 대라면 범행폰과 생활폰을 나누어 신청한다

보이스피싱이나 전자금융거래법 위반 사건의 압수목록에는 휴대폰 여러 대와 유심이 각각 올라가는 경우가 많다. 상선에게 받은 업무용 기기와 본래 쓰던 생활용 기기가 함께 압수된 경우이다. 이때 두 기기를 묶어 한꺼번에 반환을 요구할 이유가 없다. 지시를 주고받은 기기는 몰수가 예정된 물건이고, 그 반환을 다투는 일은 양형에서 반성의 부족으로 읽힐 뿐이다. 그 기기에 관하여 소유권포기서 작성을 요구받았다면 응하여도 잃을 것이 없다. 포기서가 생활용 기기의 환부청구권까지 없애지는 않는다.[7]

생활용 기기는 따로 떼어 신청한다. 핵심은 두 기기의 역할이 달랐다는 점을 수사기관의 포렌식 결과로 보여주는 것이다. 지시와 수거지 공유, 입금 보고가 모두 업무용 기기에서 나왔고 생활용 기기에서는 나오지 않았다면, 그 결과 자체가 신청의 근거가 된다. 여기에 개통일과 명의, 사용기간, 가족·직장·금융인증 용도를 붙이면 3부에서 볼 2021도5723 판결의 사실관계에 가까워진다. 이 경우 기소 전 가환부는 현실적으로 받을 수 있는 편이고, 거부되더라도 법원에 청구할 근거가 선다.[10]

유심이 따로 압수목록에 올라 있더라도 유심의 반환에 매달릴 필요는 없다. 전화번호는 통신사에 남아 있으므로 유심을 재발급받아 새 기기에 끼우면 그날부터 통화가 된다. 회선 이용료나 기기 할부금이 남아 있다는 사정은 그 자체로 몰수 여부를 결정하지 않는다.

3. 폰이 한 대라면 환부가 아니라 몰수 주문을 다툰다

생활용 기기 한 대로 상선의 지시를 받고 수거지를 공유했다면, 그 기기는 생활에도 쓰인 폰이 아니라 범행에 쓰인 폰이다. 1년 넘게 썼고 가족 사진이 들어 있더라도 형법 제48조의 '범죄행위에 제공한 물건'에 해당하고, 수사기관이 기소 전에 돌려줄 이유가 없다. 몰수 가능성이 있다는 이유만으로 가환부가 법률

상 금지되는 것은 아니다. 대법원 1998. 4. 16.자 97모25 결정은 반드시 몰수해야 하거나 소유 자체가 금지된 물건과, 형법 제48조처럼 몰수 여부를 판단할 여지가 있는 물건을 구별하고, 후자는 특별한 사정이 없으면 종국판결 전에도 가환부할 수 있다고 보았다.[2][9] 다만 조직적 범행에 쓰인 기기의 가환부를 받아 주는 수사기관이나 재판부는 드물다.

그러므로 이 경우 다툴 자리는 환부 신청이 아니라 판결의 몰수 주문이다. 형법 제48조의 몰수는 임의적이어서 비례원칙의 제한을 받는다. 범행에 쓰인 횟수와 기간, 연락의 내용, 범행용으로 개통한 기기가 아니라는 점, 몰수하지 않아도 다시 범행의 도구가 될 위험이 낮다는 점, 기기 대신 저장된 전자기록만 몰수하는 방법이 있다는 점이 그 재료이다. 자세한 내용은 3부에서 본다. 당사자에게 전할 답은 하나다. 재판이 끝나기 전에는 나오지 않고, 끝나도 몰수가 붙지 않아야 나온다. 그때까지의 연락 수단은 유심 재발급과 새 기기로 마련한다.

3부 — 범행에 사용한 휴대폰의 몰수가 뒤집힌 사건

1. 대법원 2021도5723 판결

대법원 2024. 1. 4. 선고 2021도5723 판결은 마약 사건에서 휴대폰 몰수 판단을 문제 삼았다. 피고인은 약 1년 6개월 동안 일상용으로 사용하던 기기로 범행 상대방에게 몇 차례 문자를 보내고 한 차례 통화했다. 범행 일시를 확인하기 위해 압수되었고, 제1심은 계속 보관할 필요가 없다고 보아 가환부 결정을 했으면서도 판결에서는 몰수를 선고하였다. 항소심도 몰수를 유지했다.[10]

대법원은 범행에 대한 기기의 실질적 기여와 몰수의 비례성을 충분히 심리하지 않았다고 보아 파기환송했다. 범행을 위해 별도로 마련한 기기로 보기 어려운 점, 제한적인 연락에 사용한 점, 해외 가족과의 연락과 생활에 필요한 정보가 저장된 점 등이 고려되었다. 파기환송이 곧 기기의 인도 명령을 뜻하는 것은 아니다. 환송심의 판단과 그에 따른 압수물 처리가 이어져야 한다.[10]

2. 반환을 원한다면 기기의 사용 경위를 입증해야 한다

이 판결은 범행에 제공된 물건의 범위가 실행행위에 직접 사용한 도구에만 한정되지 않는다고 보면서도, 몰수에 비례원칙의 제한이 있음을 확인했다. 기기와 저장된 전자기록을 나누어 몰수할 가능성도 설명한다. 따라서 “생활용 폰”이라는 주장만으로 충분하지 않고, 범행에 기여한 정도와 기기 전체를 잃는 불이익을 비교할 자료가 필요하다.[10]

실제 변론에서는 기기 구입·사용 기간, 범행 관련 연락의 횟수와 내용, 평소 업무와 가족 연락에 사용한 사정 등을 정리할 수 있다. 범행용으로 별도 개통한 기기인지, 여러 범행에 반복 사용했는지에 따라 결론은 달라질 수 있다. 사실관계를 확인하지 않은 채 모든 기기에 같은 판례 문구를 붙이는 방식은 설득력이 떨어진다.

검사의 몰수 구형이나 판결문에서 휴대폰이 특정되었다면 그 부분을 별도로 검토해야 한다. 징역형을 낮추는 주장에만 집중하다가 몰수 주문을 놓칠 수 있다. 증거용 보관의 필요성이 없어졌다는 가환부 주장과, 기기 전체의 몰수가 과도하다는 본안 주장을 함께 준비할 수도 있다.

4부 — 수사와 재판에서 누구에게 신청할 것인가

1. 기소 전에는 담당 수사기관부터 확인한다

수사 단계에서는 형사소송법 제218조의2에 따라 소유자·소지자·보관자·제출인이 환부 또는 가환부를 청구할 수 있다. 아직 경찰에서 사건과 폰을 취급하고 있다면 담당 경찰관에게 신청한다. 이미 송치했다는 답변을 받으면 폰도 함께 넘겼는지, 언제 어느 청으로 인계했는지와 송치 후 사건번호를 확인한다. 이후에는 인계받은 청의 사건 담당 검사에게 신청할 수 있도록 접수 창구를 확인한다. 실물의 위치를 찾는 순서는 아래 5부에서 구체적으로 살펴본다.[4]

검사가 청구를 거부하면 제218조의2 제2항에 따라 그 검사 소속 청에 대응하는 법원에 환부·가환부 결정을 청구할 수 있다. 경찰의 압수물 처리에도 이 조의 절차가 적용된다. 2026년 10월 2일부터 시행되는 개정법은 검사의 소속 기관을 공소청 및 지청으로 정비하고, 경찰의 환부·가환부는 검사의 의견을 듣고 정당한 사유가 없으면 따르도록 정한다.[4][11]

신청서에는 사건번호와 압수목록상의 기기, 신청인의 관계, 압수 및 분석의 경과, 기기를 계속 써야 할 구체적인 사정을 적는다. 기기를 특정할 수 있는 압수목록과 소유·사용 관계를 뒷받침하는 자료가 기초가 된다. 반환을 거부했다면 그 이유와 처분 내용을 확인하여 법원에 무엇을 구할지 정해야 한다.

2. 법원에 청구하는 두 절차를 혼동하지 않는다

제218조의2에 따른 법원의 환부·가환부 결정 청구와, 제417조에 따라 수사기관의 압수 또는 환부 처분의 취소·변경을 구하는 준항고는 구별된다. 원하는 결과가 휴대폰 반환이라는 이유로 절차까지 같아지는 것은 아니다. 후자는 수사기관의 처분을 다투는 방식이고, 전자는 검사의 거부 후 법원에 환부·가환부 결정을 구하는 방식이다.[4][11]

준항고는 직무집행지 관할법원 또는 검사의 소속 청에 대응하는 법원에 서면으로 청구한다. 경찰의 처분을 다투는 경우에도 처분을 한 관서와 직무집행지를 확인하여 관할을 정해야 한다. 신청서에서는 어느 기기의 어떤 압수·환부 처분을 취소하거나 변경해 달라는 것인지 특정해야 한다.[11]

대법원 2026. 6. 5.자 2026모1391 결정에서는 신청인이 제218조의2에 따라 가환부를 청구했는데, 원심이 이를 준항고로 처리하였다. 신청인은 기각 결정에 재항고장을 냈다. 대법원은 청구의 실질에 맞추어 보통항고로 보아 사건을 서울북부지방법원 합의부로 이송했다. 압수물을 반환하라고 명한 결정은 아니다.[12]

제218조의2에 따른 법원 결정에는 보통항고로 불복하고, 제417조 준항고에 대한 법원 결정에는 재항고로 불복한다. 관할과 심판 대상도 다르므로 신청 근거와 취지를 분명하게 써야 한다. 각 조문을 모두 적

어 두고 어느 절차든 알아서 받아 달라는 식으로 작성하면, 반환의 필요성을 판단받기 전에 절차를 정리하는 데 시간이 들 수 있다.[12]

3. 기소 뒤에는 사건을 심리하는 재판부에 신청한다

공소가 제기되면 환부·가환부의 판단 권한은 사건을 심리하는 법원으로 넘어간다. 기기가 수사기관의 창고에 있다고 해서 그 수사관에게 계속 허락을 구하는 구조는 아니다. 재판부에 제133조에 따른 신청을 하고, 반환 결정이 나면 법원의 사건 담당 직원에게 결정이 어느 기관에 전달되는지 확인한다. 이어 실물을 가진 청의 압수물 담당자에게 결정의 도착 여부와 수령 장소를 확인해야 한다.[3][13]

수사기관의 처분을 다투는 제417조 준항고에는 항고의 실익이 있는 한 일률적인 제기기간 제한이 없다는 대법원 결정도 있다. 그러나 공소제기 후에는 수소법원의 권한을 전제로 절차를 선택해야 한다. 과거 처분에 불만이 있다는 이유로 수사 단계의 신청 방식을 그대로 계속 사용할 수는 없다.[13]

재판부가 환부·가환부 신청을 기각한 결정에는 법원의 압수물 환부 결정에 대한 항고 절차를 검토한다. 재판장이나 수명법관의 재판을 다투는 경우에는 고지일부터 7일 이내 제416조의 준항고를 청구하는 절차가 문제 된다. 수사기관의 처분을 다투는 제417조와 혼동하지 않아야 한다. 어느 주체가 어떤 형식으로 판단했는지에 따라 불복 절차를 정해야 한다.[11]

5부 — 반환할 수 있는 폰을 실제로 찾는 법

1. 주문에서 휴대폰의 몰수를 확인한다

형사소송법 제332조는 압수한 물품에 몰수 선고가 없으면 압수가 해제된 것으로 본다. 휴대폰을 몰수하지 않은 판결이 확정되었다면, 해당 사건의 압수를 계속한다는 이유로 기기를 붙잡아 둘 수 없다. 실제 수령을 위해서는 폰을 인계받은 청의 압수물 담당자에게 판결의 확정이 반영되었는지와 교부 일정을 확인한다.[11][13]

이때 판결문에서 “징역 ○년”만 확인해서는 안 된다. 주문에 “압수된 증 제○호를 몰수한다”는 문장이 있는지, 그 증거번호가 어느 기기인지 압수목록과 대조해야 한다. 휴대폰 한 대만 몰수하고 다른 기기는 몰수하지 않은 사건도 구분해서 처리해야 한다. 별도 사건에서 다시 압수하거나 보관할 근거가 있다는 답변을 받았다면, 그 사건과 대상 기기도 특정해야 한다.

휴대폰의 몰수 선고가 확정되었다면 단순한 환부신청으로 그 형벌을 없앨 수 없다. 본안의 상소를 통해 몰수 부분을 다투어야 할 때와, 몰수되지 않은 물건을 찾아갈 때는 해야 할 일이 다르다. “재판이 끝나면 준다”는 설명을 들었더라도 몰수까지 확정되면 반환을 기대할 수 없다.

2. 내 폰이 어디 있는지 확인하는 순서

출발점은 압수할 때 받은 압수목록교부서이다. 거기에 적힌 사건과 휴대폰의 증거번호, 모델명 등 식별정보를 준비한다. 목록을 잃어버렸다면 처음 압수한 경찰관에게 해당 물건을 특정할 수 있는 목록의 재교부나 확인 방법을 문의한다. 수사기록 전체를 확보해야만 소재를 물을 수 있는 것은 아니다.[5]

먼저 담당 경찰관에게 “사건을 송치했는지”와 “이 휴대폰 실물도 인계했는지”를 함께 묻는다. 인계했다면 인계받은 청, 인계일과 확인 가능한 사건번호를 받아 둔다. 아직 경찰에 있다면 분석 부서에서 돌려받았는지, 어느 부서가 압수물로 보관하고 있는지 확인한다. 사건과 압수물의 이동은 함께 추적하되, 사건이 넘어갔다는 답변만 듣고 실물도 같은 날 이동했다고 단정하지 않는 것이다.[14]

이미 송치받은 공소청에 있다면 그 청의 민원실에 사건번호를 밝히고 ‘압수물 환부 담당’으로 연결해 달라고 요청한다. 사건과에서 접수·처리를 하고 총무과에서 실물을 보관·관리하는 등 업무가 나뉠 수 있다. 대구의 공식 부서 안내도 이 둘을 나누어 안내한다. 사건번호와 물품 정보를 제시하여 해당 폰의 압제번호, 현재 위치, 실제 수령 창구를 확인하면 된다. 압제번호를 미리 모른다고 문의를 시작하지 못하는 것은 아니다.[15][16]

재판이 시작되었다면 법원 사건번호도 함께 준비한다. 재판기록이 법원에 있다는 사실과 휴대폰 실물이 법원에 있다는 사실은 같지 않다. 폰은 해당 청에 보관된 채로 있을 수도 있고, 증거조사를 위해 법원에 제출되어 있을 수도 있다. 압수물 담당자에게 현재 법원 등에 대출 중인지까지 확인한다. 재판부의 환부 결정이 났다면 법원에는 결정의 전달처를, 실물을 가진 쪽에는 접수 여부를 확인한다.[15]

문의는 “제 폰 어디 있어요”에서 한 단계 더 나가야 한다. “○○사건 압수목록의 증 제○호 휴대전화가 현재 어디에 있고, 환부 결정이 전달되었는지, 어느 창구에서 받을 수 있는지”를 확인하는 것이다. 환부 통지를 받았다면 통지에 적힌 담당자와 수령 장소를 기준으로 방문 일정과 준비 서류를 맞춘다. 반환이 가능하다는 법적 판단과 창구에서 실제로 내어줄 준비가 끝났는지를 연결해야 한다.[15]

3. 수감 중이라면 대리수령을 준비한다

당사자가 수감 중이라면 가족이나 다른 대리인이 받도록 준비할 수 있다. 공소청에서 받는 경우에는 공소청압수물사무규칙 제49조가 요건을 직접 정한다. 대리인은 피환부인의 공공기관 발행 신분증 사본과 자필서명 또는 전자적 인증으로 작성된 위임장 등 대리권을 증명하는 서류를 제출하고, 담당 직원은 피환부인과의 전화 통화 등으로 대리권을 확인한다.[15] 공수처의 가환부 안내도 대리인의 권한을 확인할 서류와 본인·대리인의 신분 확인 자료를 요구한다. 다른 기관에서 받을 때에는 그 기관의 서식과 확인 방법을 맞추어야 한다.[17]

성인 당사자의 부모나 배우자라는 사정만으로 당연히 대신 받을 권한이 생기는 것은 아니다. 수감 중이라면 본인이 위임장에 서명하여 전달할 수 있도록 접견이나 서신 등을 통해 준비하고, 본인 신분증을 가족이 가지고 있지 않은 경우에는 어떤 대체 자료와 의사 확인 방식이 가능한지 보관기관에 먼저 협의한다. 피환부인과의 전화 확인이 절차에 들어 있으므로, 수감 중인 본인과 통화가 어렵다면 그 대체 방법도 미리 물어야 한다. 가족관계증명서만 들고 갔다가 다시 돌아오는 일을 줄일 수 있다.

수령할 때에는 인도 대상 기기의 수와 식별정보, 별도로 압수된 유심·메모리카드 등이 반환 대상에 포함되는지 확인한다. 하나의 휴대폰 사건이라도 목록에는 여러 물품이 적혀 있을 수 있다. 수령증을 작성하고 무엇을 받았는지 기록을 남겨 두는 편이 좋다. 기기 사용을 재개하는 문제는 가환부 결정의 조건과 재제출 요구가 있는지도 확인하여 처리한다.

4. 확정 뒤에도 무조건 준항고를 하는 것은 아니다

대법원 2024. 3. 12.자 2022모2352 결정은 몰수 선고 없이 판결이 확정된 이후의 절차를 분명히 했다. 이 사건은 압수물을 피해자에게 가환부한 처분을 다투는 사건이었다. 대법원은 압수가 해제된 뒤 검사에게 새로운 환부 처분 권한이 있는 것은 아니므로, 제417조 준항고로 다투는 구조가 성립하지 않는다고 보았다.[13]

따라서 몰수되지 않은 폰을 찾는 문제에서 수령 안내가 늦어진다는 이유만으로 곧바로 “환부 불허처분 취소” 준항고장을 낼 일은 아니다. 판결의 확정과 몰수되지 않은 물품을 특정하여 실물을 인계받은 청의 압수물 담당 부서에 서면으로 교부를 요청하고, 인도 예정일을 확인하는 것이 먼저다. 위임이나 신분 확인 자료가 부족하다면 보완하여 수령 절차를 진행한다. 소유권 포기서만을 이유로 국가가 인도를 거부한다면, 앞서 본 2000다27725 판결처럼 민사소송으로 환부청구권에 기초한 인도를 구하는 방법도 검토할 수 있다.[8]

다른 사건의 압수라고 한다면 그 사건번호와 압수 근거를 확인한 뒤, 그 사건의 단계에 맞추어 다시 환부·가환부를 청구해야 한다. 소유자나 반환 상대방을 둘러싼 분쟁이라면 누구에게 물건의 반환을 요구할 수 있는지와 민사상 반환청구의 필요성을 따로 검토한다. 원래 사건의 형사재판이 끝났다는 사실만으로 새로운 압수나 소유권 분쟁까지 해결되지는 않는다.

6부 — 구치소에 있는 폰은 절차가 다르다

1. 압수물과 보관품은 같은 물건함이 아니다

구속되었다고 모든 소지품이 형사소송법상 압수물이 되는 것은 아니다. 수사기관이 압수목록을 작성하여 가져간 휴대폰과, 교정시설이 입소자의 개인 물품으로 맡아 둔 휴대폰은 법적 성격과 담당 기관이 다르다. 후자는 흔히 영치품이라고 부르지만 현재 교정본부의 안내에서는 보관품이라는 용어를 쓴다.[18]

기기가 수사기관의 압수물 창고에 있다면 교도소 민원실에 반환 신청을 해도 해결되지 않는다. 반대로 교정시설의 개인 보관품이라면 담당 검사나 재판부의 가환부 결정을 받을 문제부터 시작할 필요가 없다. 당사자에게 압수목록과 보관품 내역 중 어디에 기재된 물건인지 확인하고, 현재 물건을 가진 기관을 찾아야 한다.

2. 수용자 본인이 받을 사람과 물품을 정한다

교정본부의 안내에 따르면 수용자가 받을 사람의 성명·주소·연락처와 반환할 물품을 특정하여 보관품 반환 신청서를 제출하고, 가족 등이 수령하는 방식으로 처리할 수 있다. 수용자가 택배 반환을 신청하는 방법도 안내되어 있다. 가족 쪽에서 먼저 신청하는 경로도 있다. 보관금품 관리지침 제32조 제1항 단서는 가족 등이 신청한 경우 수용자의 동의를 받아 직접 반환하거나 택배 등으로 보낼 수 있도록 정한다. 다만 어느 쪽이든 수용자의 신청이나 동의가 필요하므로, 수용자가 모르는 상태에서 가족이 찾아가 말로만 요구하면 당일 수령은 어렵다.[18][19]

현행 보관금품 관리지침 제32조는 가족 등이 신청일부터 7일 이내 방문하면 직접 반환하고, 그 기간 내 방문하지 않으면 수용자에게 미리 알린 뒤 택배 등으로 보낼 수 있도록 정한다. 이는 가족이 방문하지 않으면 일곱째 날 자동으로 소유권을 잃는다는 뜻이 아니다. 어떤 물품을 누구에게 어떻게 내보낼지 정하여 보관품 반환을 처리하는 규정이다.[19]

휴대폰을 가족에게 돌려주거나 외부에서 대신 받아 보관하게 하는 일과, 수용자가 교정시설 안에서 휴대폰을 사용하는 일은 구별해야 한다. 반환받은 기기가 곧 수용자의 생활공간으로 들어가는 것은 아니다. 수감 중에는 기기를 밖에서 받을 사람과 연락 방법을 정해 두는 것이 실무적으로 중요하다.

3. 수감 중에는 소유자의 의사를 전달할 사람도 필요하다

수감 중인 사람은 직접 압수물 담당 창구에 가거나 보관품 반환을 외부에서 처리하기 어렵다. 변호인과 가족이 사건번호, 물품 목록, 현재 보관기관, 반환 판단의 유무를 나누어 확인하고, 본인의 신청 또는 위임을 준비해야 한다. 검사나 법원의 반환 판단을 받아야 하는 폰인지, 이미 반환할 수 있는데 수령 서류만 남은 폰인지 먼저 정리해야 일이 진행된다.

가족에게는 “폰을 찾아 달라”는 말만 전달하지 말고 어느 기관이 가지고 있는지와 어떤 서류에 기재되어 있는지 알려 주어야 한다. 당사자가 이송되어 다른 교정시설에 있다는 사실도 함께 확인한다. 압수물은 사건의 이동을, 교정시설의 보관품은 수용자의 이동을 따라 확인해야 한다.

맺음

압수된 휴대폰을 둘러싼 질문은 결국 하나로 모인다. 수사기관이 그 기기를 무엇 때문에 들고 있는가이다. 증거 때문이라면 사본이 확보된 시점에 신청으로 돌려받을 길이 열리고, 몰수 때문이라면 재판에서 몰수 주문을 다투는 길만 남으며, 판결이 확정되었다면 남은 일은 소재 확인과 수령 서류뿐이다. 세 길은 신청의 상대방과 근거 조문, 불복 방법이 모두 다르다. ‘제 폰은 언제 주나요’라는 질문에 돌려줄 답도 그 기기가 셋 중 어디에 있는지에 따라 정해진다.

참고 판례 및 법령

[1] 형사소송법 제106조 제1항 — 증거물 및 몰수 대상 물건의 압수.
형사소송법 제106조
[2] 형법 제48조 — 몰수 대상, 소유관계 요건 및 전자기록 일부의 처리.
형법 제48조
[3] 형사소송법 제133조 — 재판 단계의 환부·가환부 및 계속 사용할 증거물의 원형보존.
형사소송법 제133조

[4] 형사소송법 제218조의2 — 기소 전 환부·가환부, 거부 후 법원 청구 및 경찰에 대한 적용.
형사소송법 제218조의2
[5] 형사소송법 제218조·제219조·제129조 — 임의제출물의 영장 없는 압수 및 압수목록 교부.
형사소송법
[6] (경찰청) 범죄수사규칙 제139조·제142조 — 소유권포기서, 임의제출서와 소유권 포기 의사의 기재. 2026. 10. 2. 시행 경찰청훈령 제1232호.
범죄수사규칙
[7] 대법원 1996. 8. 16.자 94모51 전원합의체 결정 — 소유권 포기와 형사소송법상 환부청구권의 구별 및 환부청구권 포기의 효력.
94모51 전원합의체 결정
[8] 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000다27725 판결 — 소유권 포기 확인서 작성 후 몰수 없이 판결이 확정된 압수물의 인도청구.
2000다27725 판결
[9] 대법원 1998. 4. 16.자 97모25 결정 — 소유권 포기의 환부청구권에 대한 영향 및 임의적 몰수 대상 압수물의 가환부 가능성.
97모25 결정
[10] 대법원 2024. 1. 4. 선고 2021도5723 판결 — 휴대폰 몰수의 실질적 요건과 비례원칙. 몰수 판단을 포함한 원심 파기환송.
2021도5723 판결
[11] 형사소송법 제332조, 제402조·제403조, 제416조부터 제419조까지 및 제218조의2 — 판결과 압수 해제, 항고·준항고. 2026. 10. 2. 시행 개정법의 소속 기관 및 경찰 환부·가환부 규정 포함.
형사소송법 2026년 10월 2일 시행본
[12] 대법원 2026. 6. 5.자 2026모1391 결정 — 제218조의2에 따른 가환부 청구와 제417조 준항고의 구별 및 불복 방법. 법원도서관 공개 결정 요지 참조.
2026모1391 결정 요지
[13] 대법원 2024. 3. 12.자 2022모2352 결정 — 공소제기 후의 처분권한, 몰수 없이 판결 확정 후 압수 해제, 수사기관 처분에 대한 준항고의 제기기간.
2022모2352 결정
[14] 경찰수사규칙 제103조 — 사건 송치 서류와 압수물총목록.
경찰수사규칙 제103조
[15] 공소청압수물사무규칙 제4조·제8조, 제25조부터 제27조까지, 제49조 — 압수물 인수, 압제번호, 법원 등에 대한 대출, 환부·인도 절차와 대리수령 요건. 2026. 10. 2. 시행(구 검찰압수물사무규칙에서 제명 변경).
공소청압수물사무규칙 · 국가법령정보센터
[16] 대구지방공소청 부서별 업무 안내 — 사건과의 압수금품 접수·처리와 총무과의 압수금품 보관·관리, 민원실 안내.
대구 부서별 업무 안내
[17] 고위공직자범죄수사처 민원 안내 중 압수물 가환부 신청 — 신청인, 대리 접수 자료 및 결정 후 교부 절차.
공수처 압수물 가환부 안내
[18] 법무부 교정본부 보관금품 FAQ — 영치품과 보관품의 명칭, 보관품 반환 신청 및 방문·택배 수령.
교정본부 보관금품 FAQ
[19] 보관금품 관리지침 제32조 — 수용자의 가족 등에 대한 보관품 반환 절차. 2025. 1. 2. 시행 법무부예규 제1355호.
보관금품 관리지침

이 달의 판례

부당이득 반환액을 공평의 원칙으로 줄일 수 있는가

대법원 2026. 9. 10. 선고 2026다203472 판결

사실관계 — 사용이익의 반환을 2천만 원으로 제한한 원심

원고는 자신의 토지를 법률상 원인 없이 점유·사용한 피고에게 그 기간의 차임 상당액을 부당이득으로 반환하라고 청구하였다. 원심도 반환의무 자체는 인정하였다. 다만 피고가 토지를 사용하게 된 경위와 토지 인도에 관한 임의조정의 성립 과정 등을 고려하여, 반환액을 청구금액의 30%를 조금 넘는 2,000만 원으로 제한하였다.[1]

사용한 토지의 면적이나 기간을 달리 인정하여 금액이 줄어든 사건은 아니었다. 원심은 반환책임을 인정한 다음, 공평의 원칙을 근거로 그 책임을 제한하였다. 남의 토지를 사용한 이익을 돌려주는 사건에서도 양쪽 사정을 참작하여 책임비율을 정할 수 있는지가 쟁점이 되었다.

대법원의 판단 — 공평을 이유로 다시 깎을 수는 없다

대법원은 원심의 감액 판단을 받아들이지 않고 일부 파기환송하였다. 부당이득으로 반환할 이익에 대하여 손해배상의 과실상계와 같이 신의칙이나 공평을 내세워 반환 범위를 제한하는 것은 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다고 보았다. 이 사건에서 피고가 반환할 것은 점유기간에 상응하는 차임 상당액 전액이라는 판단이다.[1]

부당이득도 공평과 정의를 바탕으로 하는 제도이다. 다만 그 고려는 이미 부당이득의 성립요건과 반환 범위를 정한 규정에 반영되어 있다. 대법원은 개별 규정만으로 사안을 공평하게 해결할 수 없는 경우에

한하여 신의칙이나 공평의 이념이 보충적으로 적용된다고 설명하였다. 규정에 따라 반환액을 산정해 놓고 추상적인 공평을 이유로 다시 줄이는 데에는 한계가 있다는 것이다.[1]

손해배상에서는 피해자의 잘못이 손해의 발생이나 확대에 기여하였다면 과실상계가 가능하다. 민법 제396조와 제763조가 그 근거이다. 부당이득반환은 법률상 원인 없이 상대방에게 넘어간 이익을 되돌리는 문제이므로, 손해의 분담에 관한 법리를 그대로 적용할 수 없다.[2]

같은 토지를 둘러싼 분쟁에서도 토지를 훼손한 데 대한 손해배상과, 권한 없이 사용한 데 대한 사용이익 반환은 계산의 출발점이 다르다. 손해배상 사건에서 익숙한 책임비율을 돈을 돌려주는 모든 사건에 적용할 수 있는 것은 아니다.

기존 법리 — 계약 해제 뒤의 대금 반환도 마찬가지였다

계약이 해제된 뒤 매매대금을 돌려주는 사건에서는 이미 같은 법리가 제시되어 있었다. 대법원 2014. 3. 13. 선고 2013다34143 판결이다. 매도인이 택지 분양권의 수분양자 명의를 제3자에게 변경하여 매수인에 대한 이행이 불가능해지자, 매수인은 계약을 해제하고 지급한 1억 4,500만 원의 반환을 청구하였다.[3]

원심은 매수인에게도 사정이 있다고 보았다. 분양권 확보에 필요한 서류를 다른 사람에게 맡겨 두었고, 그 때문에 매도인이 그 사람에게 전매 권한이 있다고 믿었다는 것이다. 원심은 이를 참작하여 반환책임을 대금의 40%인 5,800만 원으로 제한하였다. 그러나 대법원은 원상회복의무에 과실상계를 적용할 수 없고, 신의칙이나 공평을 들어 같은 방식으로 제한할 수도 없다며 파기하였다.[3]

계약 해제에 따른 원상회복을 정한 민법 제548조는 부당이득에 관한 특별규정이다. 계약에 따라 주고받은 급부가 없었던 상태로 되돌리는 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 받은 이익 전부가 반환 대상이 된다. 이번 판결은 이 법리가 일반적인 부당이득반환에도 적용된다는 점을 분명히 하였다.[1][3]

계약 해제와 함께 손해배상을 청구할 수 있다는 민법 제551조도 이 구별을 전제로 한다. 돌려받을 대금과 계약 위반으로 배상받을 손해는 같은 소송에서 청구할 수 있지만, 반환과 배상을 계산하는 법리는 각각 적용된다. 계약이 깨지는 과정에 매수인의 잘못이 있었다는 이유만으로 매도인이 이미 받은 대금의 일부를 보유할 근거가 생기지는 않는다.[2]

실무 함의 — 반환 범위와 반대채권을 구체적으로 다툰다

이 판결로 부당이득반환청구에 대한 방어가 사라지는 것은 아니다. 사용 권한이 있었던 기간, 실제 사용한 면적, 차임 상당액의 산정, 이미 지급한 금액은 여전히 반환액을 결정한다. 가령 소유자가 한동안 이의를 제기하지 않았다는 사정도, 그 기간에 무상 사용을 허락한 계약이 있었다는 증거라면 의미가 달라진다. 법률상 원인이 인정되는 기간에는 애초에 부당이득이 성립하지 않기 때문이다. 단순한 묵인만으로 그러한 계약이 당연히 인정되는 것은 아니다.[2]

법률이 정한 반환 범위도 남는다. 민법 제748조는 선의의 수익자에 대하여 현존하는 이익의 한도에서 반환하도록 하고, 악의의 수익자에게는 이자와 손해배상 책임을 더한다. 여기서 선의·악의는 이익을 보유할 법률상 원인이 없다는 사실을 알았는지에 관한 구별이다. 물건의 점유·사용에서는 민법 제201조의 과실취득 규정 등도 적용된다. 다만 앞서 본 계약 해제의 원상회복은 특별규정에 따라 받은 이익 전부의 반환이 원칙이므로, 일반 부당이득의 현존이익 제한을 그대로 적용할 수 없다.[3][4]

비용을 지출한 경우에는 그 비용을 돌려받을 권리가 있는지가 중요하다. 대법원 2021. 4. 29. 선고 2018다261889 판결에서는 상속받은 건물을 단독으로 점유하던 사람이 다른 공유자에게 차임 상당액 등을 지급할 의무를 부담하였다. 그런데 건물 관리에 지출한 통상의 필요비 중 원고 지분에 해당하는 1,671만 3,519원은 지급할 금액에서 공제되었다.[5]

민법 제203조 제1항 단서는 점유자가 과실을 취득한 경우 통상의 필요비를 청구하지 못한다고 정한다. 대법원은 이 제한이 과실을 취득할 권리가 있는 선의의 점유자에게 적용되는 것이며, 과실을 반환해야

하는 악의의 점유자에게까지 적용되는 것은 아니라고 보았다. 공제의 근거는 피고도 건물을 관리하느라 고생했다는 사정 자체가 아니라, 법률이 인정하는 필요비 상환청구권이었다.[5]

상대방에 대한 손해배상채권이 있다면 상계도 가능하다. 예컨대 계약 해제로 반환할 선급금과 별개로 상대방의 계약 위반에 따른 손해배상채권이 발생하였고 상계 요건을 갖추었다면, 그 채권으로 반환채무를 소멸시킬 수 있다. 이때에는 손해배상채권의 발생 원인과 금액을 주장·증명하고 상계의 의사표시를 하여야 한다. '상대방도 잘못했으니 절반만 돌려주겠다'는 주장만으로 그 과정을 대신할 수는 없다.[2]

당사자가 소송 기간과 회수 가능성을 고려하여 반환액을 낮추는 합의를 하는 것은 가능하다. 그러나 합의로 양보하는 금액과 판결로 인정될 채무액은 다르다. 이번 판결이 제한한 것은 법률상 반환할 이익을 정한 뒤 사정을 참작하여 일정 비율을 깎는 방식이다. 반환을 거절할 근거가 있거나 상대방에게 받을 채권이 있다면 그 법률관계로 다투어야 한다. '사정은 서로 있었으니 법원이 적당히 깎아 주겠지'라는 기대만으로는 방어가 되지 않는다.

근거 자료

[1] 대법원 2026. 9. 10. 선고 2026다203472 판결. 신의칙·공평을 이유로 한 부당이득반환책임 제한. 일부 파기환송.
대한민국 법원 · 2026다203472 판결 요지와 첨부 판결문
[2] 민법 제396조, 제492조·제493조, 제548조·제551조, 제741조, 제763조. 과실상계, 상계, 계약 해제에 따른 원상회복과 손해배상, 부당이득의 성립요건.
국가법령정보센터 · 민법
[3] 대법원 2014. 3. 13. 선고 2013다34143 판결. 계약 해제에 따른 매매대금 반환책임을 공평의 원칙으로 40%로 제한한 원심 판단을 파기한 사례.
국가법령정보센터 · 2013다34143 판결
[4] 민법 제748조·제749조 및 제201조. 수익자의 반환범위, 악의인정 및 점유자의 과실취득.
국가법령정보센터 · 민법 제748조
국가법령정보센터 · 민법 제749조
[5] 민법 제203조 및 대법원 2021. 4. 29. 선고 2018다261889 판결. 악의의 점유자의 통상 필요비 상환청구와 공제.
국가법령정보센터 · 2018다261889 판결

월간궤도 · MONTHLY GWEDO
제7호 · 2026년 10월
발행 / 신한솔 변호사
이 문서에 수록된 내용은 법률자문을 대체하지 않습니다.
구체적인 사안에 대한 판단은 반드시 변호사와의 상담을 거쳐야 합니다.
orbitlaw.co.kr